

1500633-11.2022.8.26.0213

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PUGLIESI LEITE

Comarca: Guará

Foro: Foro de Guará

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - agente que não é preso em flagrante vendendo a droga - Quantidade apreendida - Circunstâncias objetivas do crime - Configuração do ilícito. Para configuração do delito de tráfico, e irrelevante a quantidade maior ou menor da droga apreendida, nem é necessário que o agente seja surpreendido a vende-la, porque outras provas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guará

Foro de Guará

1ª Vara

Rua Carlos de Campos, 260, Guara-SP - cep 14580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500633-11.2022.8.26.0213 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500633-11.2022.8.26.0213

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297459/2022 - DEL.POL.GUARÁ, 28377255 - DEL.POL.GUARÁ, 2297459 - DEL.POL.GUARÁ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FERNANDO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. ADRIANO PUGLIESI LEITE

Vistos.

GABRIEL FERNANDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 30 de outubro de 2022, aproximadamente às 21h59min, na Rua João Gimenés Guerreiro, nº 271, nesta cidade e Comarca de Guará/SP, tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 37,67g (trinta e sete gramas e sessenta e sete centigramas) de cocaína, das quais 37,48g na forma de crack e 0,19g em pó, além de 34,15g (trinta e quatro gramas e quinze centigramas) de maconha, drogas estas causadoras de dependência física e psíquica.

A inicial narra que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando receberam informação anônima de que um indivíduo estaria agredindo a esposa a pauladas. Dirigiram-se ao local e ao chegarem, se depararam com o portão aberto,

chamaram pelo morador, quando o denunciado apareceu no quintal e repentinamente retornou para o interior do imóvel. Em razão dos fortes indícios da prática de crime no local, os policiais entraram no imóvel quando notaram que havia sobre um sofá, um prato contendo uma pedra e diversos pedriscos de crack, lâmina de barbear, quatro rolos pequenos de plástico filme, uma tampa de garrafa plástica envolta por plástico, contendo pó em seu interior, além de uma porção de maconha, tudo a indicar que a porção maior de cocaína e a porção de maconha estavam sendo preparadas para serem divididas em porções pequenas, para posterior revenda. Ao ser submetido a revista pessoal, foram localizados R\$382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) em espécie, em notas diversas.

Em audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva e o réu, pessoalmente citado, aos 31 de outubro de 2022 (fls. 56/59). A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2022 (fl. 84) e o réu apresentou resposta à acusação, às fls. 79/81. Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas e interrogado o réu (fl. 117).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pleiteou a condenação do réu por entender comprovadas materialidade e autoria (sistema informatizado - SAJ).

Por sua vez, a defesa requereu, preliminarmente, a realização de nova perícia para apuração da qualidade da droga apreendida e de exame toxicológico a fim de comprovar a condição de dependente químico do acusado. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, ao argumento de ausência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico para o de uso (fls. 118/123).

É o relatório. Fundamento e decido.

Preliminarmente, não merecem acolhida os requerimentos para realização de nova perícia da droga apreendida e a realização de exame de dependência toxicológica, formulados pela nobre defesa do réu, pois a fase instrutória já foi encerrada por não haverem mais diligências a se realizar, o que tornam preclusos tais pedidos. Ademais, não há que se falar em qualquer irregularidade no exame procedido, porquanto assinado por perito criminal e compatível com o material consignado no auto de exibição e apreensão de fls. 21/22. E, ainda, a realização de exame de dependência toxicológica se justifica apenas quando o magistrado verificar a sua necessidade através da análise do conjunto de elementos de convicção, a simples declaração de ser o réu usuário de drogas, por si só, não torna obrigatória a instauração do incidente. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

"A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que '[não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de diligências requeridas pela defesa, se foram elas consideradas desnecessárias pelo órgão julgador a quem compete a avaliação da necessidade ou conveniência do procedimento então proposto]' [HC nº 76.614, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 12.06.1998]." (STF - HC 99.015, Rel. Min. Eros Grau; 2ª Turma; DJ. 23.06.2009).

"O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa (Precedentes do STF e do STJ)" (STJ - HC nº 106.890; Rel. Min. Felix Fischer, DJ. 02.12.2008).

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DESNECESSIDADE. 1. O paciente foi preso em flagrante, juntamente com outro corréu, por ter, em depósito, grande quantidade de diversos entorpecentes. 2. Não ficou demonstrada a necessidade de realização do exame de dependência toxicológica, sendo certo que a simples alegação de que o paciente é

usuário de drogas não é argumento apto a autorizar a realização de tal exame. A falta do exame não configura nulidade se outros elementos de convicção justificam sua dispensa. Tal exame mostra-se necessário apenas quando há dúvida a respeito do poder de autodeterminação do acusado. 3. Ordem denegada." (STJ - HC 99006/SP HABEAS CORPUS 2008/0012587-3; Rel. Min. OG FERNANDES; 6ª Turma; DJ. 10/03/2009). grifei

"APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS Pleito de instauração de incidente de dependência toxicológica Desnecessidade Ausência de indícios de que o agente era inimputável pela dependência química (...) ausente qualquer indício de que eventual uso de drogas teria comprometido o entendimento e a autodeterminação do agente, descabe a realização da aludida perícia e a indevida procrastinação do processo. A propósito, já decidiu este E. Tribunal: "E não há que se falar em nulidade processual, como pretendem as duntas Defesas de Marcos Roberto e Ademilson, ante a inexistência de exame de dependência toxicológica. Com efeito, a instauração de tal incidente é de prudente discricionariedade do magistrado, desde que haja elementos de dúvida sobre a imputabilidade penal do agente. (Ap. n.º 0005166-81.2007.8.26.0288, rel. Louri Barbiero, j. em 15.02.2012)." (TJSP - Apelação Criminal nº 0025140-97.2014.8.26.0114; 4ª Câmara de Direito Criminal; Rel. Camilo Léllis; DJ. 10.11.2015). grifei

Preliminar - Liberdade provisória até o trânsito em Julgado - Pleito rejeitado - Comprovada materialidade e autoria delitivas - Réu já condenado em primeiro grau e condenação mantida por esta Instância - Presentes requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Preliminar - Cerceamento de Defesa - Instauração Incidente de Dependência Toxicológica -- Descabimento - Mera indicação de que o réu seria dependente químico - Ausentes indícios nos autos - Incidente não pleiteado em nenhuma outra oportunidade - Pleito rejeitado. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1501097-09.2021.8.26.0621; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lorena - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022). grifei

Apelação. Tráfico de Drogas. 1. (...) 1.1 Nulidade do laudo pericial. Afastamento. Divergência suscitada pela defesa que não prejudica a materialidade delitiva. Laudo provisório que se presta a caracterizar a materialidade, para fins de flagrante. Laudo definitivo consistente em documento que deve amparar a sentença condenatória. Entendimento divergente na jurisprudência acerca da prescindibilidade de ambos os exames. Precedentes. Contudo - seja de uma forma ou de outra - comprovação da natureza de ilícita da substância apreendida. Caso dos autos. Dúvida acerca da natureza da droga apreendida [cocaína] incorrente. Exame toxicológico que faz referência aos apelantes como responsáveis pela droga, além de indicar o mesmo R.D.O constante no ofício de requisição do laudo. Afastamento da nulidade. Materialidade comprovada. (...) (TJSP; Apelação Criminal 0000354-39.2017.8.26.0613; Relator (a): Luís Geraldo Lanfredi; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022). grifei

No mérito, a pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, boletim de ocorrência de fl. 9/13, auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 113/116.

A autoria também é evidente.

O acusado, ao ser interrogado, negou a prática delitiva. Disse que tem 28 anos. É amasiado e sem filhos. Trabalha na roça avulso. Respondeu processo por tráfico e lesão corporal. Fazia quarenta dias que estava solto. Alexia fez empréstimo e usa crack, cocaína e maconha. Discutiram e depois voltou para casa. Chegou a Michele. Saiu, deixou o crack no sofá. Foi abordado pela polícia. Eles acharam o crack. Foi

agredido pelos policiais. Tinha uma pedra de crack que não era sua. Disse que não foi agredido (sistema informatizado - SAJ).

Contudo, vê-se que a negativa apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório presente nos autos, em especial pelos firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência. Vejamos.

A testemunha Gabriel Rodrigues, Policial Militar, relatou que estava no atendimento do 190 quando foram chamados para atender ocorrência de violência doméstica. A mulher estaria sendo agredida. Ele saiu correndo para dentro e voltou agressivo. Viram na casa a droga, papel filme, uma gilete. Fizeram a revista pessoal e acharam também maconha e cocaína. Ele estava bastante alterado e foi encaminhado ao hospital e à delegacia. A esposa chegou com hematomas, mas disse que não tinha sido ele. Ele disse que a droga era para seu consumo. Quando entraram, tinham feito contato pelo portão - entraram porque era denúncia de espancamento de mulher. O sofá fica no quintal dele. Tinha papel filme. Ele tinha trezentos e oitenta e poucos reais. A droga estava cortada em porções menores. Foi a primeira vez que foi a esse endereço (sistema informatizado - SAJ).

No mesmo sentido, a testemunha Adriano José Almeida, Policial Militar, informou que após as eleições receberam ligações relatando que ele estaria batendo na esposa com pauladas. Tiveram umas três ligações. O portão estava aberto e ele correu para dentro da casa. Entraram para apurar a agressão e visualizaram um sofá com um prato com crack, gilete e papel filme. Com ele tinha quase quatrocentos reais, mais um pino de cocaína e maconha. Ele disse que era para uso pessoal. Ele passou pela Santa Casa e foram para o plantão de Ituverava. Ele tinha papel filme também e uns três rolos abertos. Não o conhecia (sistema informatizado - SAJ).

É de se consignar, neste momento, que é digno de crédito o depoimento dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Primeiro porque sua declaração na fase extrajudicial e judicial foi segura e coerente. Segundo, porque não se extrai dos autos qualquer indício de que seu objetivo seria o de incriminar injustamente o réu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Nesse sentido:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória" (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a validade do depoimento de policiais como prova, quando convergente com os demais elementos existentes nos autos:

"PROCESSUAL PENAL - PENAL - TESTEMUNHA POLICIAL - PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de 'habeas corpus', o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido". (STF - HC nº 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse

servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

A testemunha Alexia Fernanda Silva Piveta declarou que é esposa do acusado. No dia dos fatos se desentenderam. À noite ele pediu dinheiro para comprar lanche e mantimentos. Ele voltou com o crack. Ele foi usar a droga e os vizinhos o denunciaram para a polícia. Ele tinha feito uso de cocaína e maconha mais cedo. Usou maconha e cocaína com ele antes. Trabalham na roça e tinha pegado empréstimo do governo. Tinha uns quinhentos e trinta reais desse empréstimo. Tem tatuagem no pescoço. Não sabe o que significa. Já foi condenada por tráfico (sistema informatizado - SAJ).

A testemunha Michele Cristina Pereira de Oliveira asseverou que é amiga da mãe dele. No dia dos fatos presenciou discussão do casal. Foi porque era amiga deles. Mora perto. Não sabe de traficância no local. O local é muito calmo. Eles estavam alterados da droga. Sabia que ele esteve preso por tráfico e foi solto quarenta dias antes. Foi no domingo da eleição (sistema informatizado - SAJ).

Nesse contexto, a apreensão da droga, a quantidade e variedade encontrada, a forma de seu acondicionamento, além de petrechos comumente utilizados para preparar drogas para a venda (lâmina de barbear, rolos de plástico filme), além de dinheiro, são fatores que corroboram a versão dos policiais e a tese da acusação. E, ainda, não é comum que usuários comprem grande quantidade de maconha e cocaína para manter em estoque. Portanto, induvidoso que o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, substância entorpecente.

Consigno, também, que a entrada dos policiais no imóvel é justificada pelos relatos de agressões sofridas pela mulher, para fim de prestar socorro, bem como que a droga estava em área externa do imóvel e estava sendo fracionada para venda, inclusive com rolos de plástico filme.

Importa consignar, ainda, que, embora o réu tenha declarado em seu interrogatório que é usuário de drogas, o fato é que a condição de usuário de entorpecente não tem o condão de afastar o exercício do comércio de drogas. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante, coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilita-se a compra, para que o vício possa ser sustentado, o que faz ainda mais reprovável sua conduta.

Além do mais, para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta "ter em depósito" ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, a jurisprudência:

"(...) o tráfico de droga dispensa a prática de ato de comércio à sua configuração, pois é crime de perigo abstrato, o qual se consuma com a simples guarda e depósito de substância entorpecente, afetando a saúde pública, que constitui o bem jurídico tutelado" (TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013).

"CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - agente que não é preso em flagrante vendendo a droga - Quantidade apreendida - Circunstâncias objetivas do crime - Configuração do ilícito. Para configuração do delito de tráfico, e irrelevante a quantidade maior ou menor da droga apreendida, nem é necessário que o agente seja surpreendido a vende-la, porque outras provas, circunstâncias

objetivas, podem convencer o julgador acerca da existência do crime e sua autoria, como autoriza o artigo 37 da Lei Antitóxicos" (TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Prova - Palavra das rés que admitiram trazer consigo a droga - Depoimento de policiais - Validade - A reação apresentada pelas rés quando flagradas é incompatível com o alegado desconhecimento do conteúdo dos pacotes - A quantidade e o modo de acondicionamento revelam o intuito de comércio - Pena - Substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direito - Inadmissibilidade - Recursos não providos" (TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99).

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização" (RT 714/357).

Assim, a alegação da defesa não merece prosperar, já que não há que se falar em ausência de provas da prática do tráfico. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu a autoria do delito. E não se espera, em casos que tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.

Logo, comprovado o tráfico, não há que se falar em desclassificação para a posse da droga para uso próprio.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido (R\$382,00), nada indica que tenha origem lícita e deverá ser revertido ao FUNAD.

Em conclusão, pelas condições reveladas acima, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê como pena a privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui maus antecedentes (fl. 46), razão pela qual fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Pela agravante da reincidência (fl. 44) e com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6, o que resulta em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Ausente circunstância atenuante.

Descabida a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, eis que o réu não atende a seus requisitos, pois é reincidente específico.

Assim, torno a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, "b", do Código Penal. Mesmo considerando o fato de o réu encontrar-se preso preventivamente desde 31.10.2022, e aplicando-se a detração (artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal), o regime, ainda assim, é o fechado tendo em conta a reincidência do acusado.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico nos moldes praticados pelo réu inviabiliza tais benefícios legais (art. 44, inciso III e art. 77, inciso II, do Código Penal), bem como que insuficiente à repressão e prevenção do crime, conforme fundamentação supra.

No mais, considerando que o réu respondeu ao processo preso, concluo que persistem as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão cautelar, já que interessante à ordem pública e ao próprio prestígio do Poder Judiciário, pelo restabelecimento do sentimento de punição aos autores de delitos. E mais, se respondeu preso ao processo, seria no mínimo contraditório agora, em juízo de cognição exauriente (o que caracteriza o *fumus comissi delicti*), sua condenação e soltura. Some-se sua reincidência, a caracterizar também o *periculum libertatis*. Assim, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar GABRIEL FERNANDO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, negado eventual apelo em liberdade.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06, declaro perdido em favor da União, o valor apreendido em poder do réu (R\$382,00), que será revertido diretamente ao FUNAD. Transitada em julgado a sentença, remeta-se à SENAD relação do valor apreendido com indicação da instituição em que se encontra depositada.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça, que ora lhe concedo, ante sua evidente hipossuficiência econômica.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para suspensão dos direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Recomende-se o condenado no estabelecimento prisional em que se encontrar.
P.R.I.C.

Guara, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA